

2012년 제 49회 변리사 2차시험 상표법 논점해설

-공성철, 원대규 변리사-

2차 시험 보시느라 정말 수고하셨습니다.

올해 시험은 학원가의 중요 논점 사항들이 출제되었습니다. 다소 난감한 단문 문제가 있었지만 법전을 중심으로 충분히 단문으로 만들어 낼 수 있는 문제였기에 전체적으로 큰 어려움은 없으셨을 것으로 사료됩니다.

A-1 문제의 경우 진정상품병행수입 문제로서 수험가에서 이미 중요논점을 거론되던 사항이었으므로, 보다 명확한 정리로서 답안을 구성하심이 특점에 유리할 수 있고, 특히, 판매지 제한 약정 판례가 중요할 수 있다고 봅니다.

A-2 문제의 경우 표장자체에 대한 6조1항3호에서는 도안화를 고려하시고 타인의 상표와 있어서 7조1항12호에서는 속지주의와 부정한 목적이 중심이 될 수 있다고 봅니다.

B-1 문제의 경우 상표권의 공유, 동종성 판단 및 타인해당여부에 따라 7조1항7호를 논해 주시고, 그 극복조치로서 타인 해당여부의 극복과 출원일체원칙의 극복이 주논점이 될 수 있다고 봅니다.

B-2 문제의 경우 상표권 이전에 관련된 것으로서 수험가에서 따로 준비하는 단문 사항은 아닙니다. 다만, 수험생 여러분들이 대부분은 아시는 내용이므로, 법조문을 중심으로 충분 단문의 재구성이 가능할 수 있습니다. 순발력이 다소 요구되는 문제였다고 봅니다.

올해 상표법은 전체적으로 무난한 문제와 논점들로 구성되었습니다. 다만, 각 수험생간의 답안 작성 스킬에 차이가 있으므로 상기 스킬 차이에 따른 차이가 예상될 수 있다고 봅니다. 그 동안 공부하시느라 정말 고생하셨습니다. 고생한 만큼 모두 보답 받으시길 진심으로 기원합니다.

감사합니다.

-공성철, 원대규 올림-

[A-1] 진정상품병행수입 관련

甲은 1900년에 영국에서 설립된 이래 고급 의류 및 핸드백, 가죽제품 등을 제조·판매하는 다국적 기업으로서 1988. 8. 8.에 영국에서 의류, 핸드백, 가죽제품에 대하여 상표(이하, '이 건 등록상표'라 한다.)등록을 마친 것을 비롯하여 미국, 일본, 독일에서 동일한 상표를 보유하고 있다. 甲은 국내에서도 이 건의 등록상표와 동일한 상품에 출원하여 2002. 2. 2.에 상표등록을 받았다.

乙은 미국에서 의류 도소매업을 목적으로 설립된 회사로서 2005. 3. 2.에 甲이 영국에서 생산한 의류를 甲으로부터 수입하여 미국 내에서만 독점 판매하는 것을 내용으로 하는 이 건의 등록 상표에 대한 전용사용권을 설정받았으며, 2005. 5. 1.부터 미국에서 판매하고 있다.

丙은 1999년에 의류수출업 및 도소매업을 목적으로 설립된 국내 회사로서, 2008년부터 甲이 영국에서 생산한 의류와 乙이 전용사용권을 설정받아 미국에서 판매하고 있는 의류를 수입하여 서울 강남구 삼성동 소재 직영매장에서 판매하고 있다.

(1) 丙이 영국으로부터 甲의 의류를 수입·판매하는 행위가 상표법상 허용되는지, 허용된다면 그 이론적 근거 및 허용요건에 관한 일반론을 논하시오. (20점)

(2) 乙에 의해 미국에서만 판매되고 있는 甲의 의류를 丙이 국내로 수입·판매하는 행위가 허용되는지 여부를 논하시오. (10점)

〈출제〉 49회 상표법 기출

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제점

2. 진정상품병행수입의 허용여부

(1) 문제점

(2) 견해의 대립

- 1) 긍정하는 견해(①파리조약상 독립의 원칙, ②정당권리자 신용훼손우려, ③속지주의원칙)
- 2) 부정하는 견해(①국제적 소진이론, ②상표의 기능론, ③Googwill 보호론)

(3) 판례의 태도

(4) 검토 및 사안의 경우

3. 진정상품병행수입에 대한 요건

(1) 침해요건 판단

(2) 진정상품 병행 수입의 허용요건

判例는 i) 국내의 상표권자 동일, ii) 진정상품 iii) 출처인식 동일, iv) 상표품의 품질 동일 要.

(3) 사안의 경우(판례 요건에 따른 포섭)

4. 소결

(1) 수입·판매행위

丙의 행위는 甲에 대한 상표법상 침해×, 부정법상 부정경쟁행위 ×. ∴ 허용.

(2) 매장에서의 판매 관련

사실관계가 거의 없으므로 짧게 or 논외로 처리

5. 관련문제

병행수입과 관련된 행정부의 규정

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제점

2. 병행수입과 진정상품

(1) 미국의 상표권자 및 국내의 상표권자 甲 동일

(2) 외국에서 적법하게 유통된 진정상품

(3) 판매지 제한약정의 경우

1) 문제점

2) 판례의 태도

3) 검토

(4) 사안의 경우(판례 요건에 따른 포섭)

3. 소결 및 관련문제

[A-2] 식별력 판단 및 특정출처인식상표에 대한 보호

甲은 2012. 2. 1.에  ('이하, '이 건 출원상표'라 한다.)를 '스파게티, 피자'에 대하여 특허청에 상표등록출원을 하였다. 한편, 미국인 乙은 미국 네바다주 라스베가스의 중심가에 식당을 개업한 때인 1980년경부터 지금까지 30여년간 이 건 출원상표인  와 동일한 표장인  를 자신의 식당의 상호로 사용함으로써 해당 식당 명칭은 미국의 일반수요자 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 서비스표로 인식되게 되었다. 이 사안에서 甲의 이 건 출원 상표에 대한 상표등록가능성 및 그 이유에 대하여 설명하시오. (20점)

(단, 'PREMIER'는 "최고의, 최고급의"라는 의미로 대중에게 인식되고 있음.)

◁출제▷ 49회 상표법 기출

I. 문제의 소재

+ 法7①(9) 내지 ⑪)후단 논의

II. 甲의 등록가능성 및 그 이유

1. 法6①(3)의 판단

- (1) 취지
 - (2) 성질표장인지 여부
 - (3) 보통 사용하는 방법으로 표시여부
- 도안화 → 문자인식력 압도 ∴ 적용 없음.

2. 法7①(11)전단의 판단

- (1) 취지
 - (2) 사안의 경우
- 품질의 객관화 불능(판례) ∴ 적용 없음.

3. 法7①(12)의 판단

(1) 취지

(2) 지역적 범위

속지주의 원칙의 예외

(3) 수요자의 인식 정도

1) 2007년 7월 1일 개정법

주지도 완화.

2) 특정출처인식여부 판단

판례에 따른 포섭

(4) 부정한 목적 판단

※ 동종성 판단은 부정한 목적 안에서 간단히 언급 가능.

(5) 사안의 경우

4. 法7①(6)의 판단

국내 저명성 취득 無 ∴ 적용 없음.

III. 소결 및 관련문제

[B-1] 등록상표의 등록배제효에 대한 주체적 요건 및 동종성 판단

甲과 乙은 함께 주유소를 운영하면서 주유소의 상호를 'X'로 선정하고 주유소업을 지정서비스업으로 하면서 甲과 乙의 공동명의로 서비스표등록출원을 하여 2010. 2. 2.에 등록을 받았다. 그 후 甲은 乙과 사업적으로 결별하고 독자적인 사업을 시작하면서 '휘발유, 자동차백미리'를 지정상품으로 하여 상표 'X'를 甲 명의로 2011. 3. 3.에 상표 등록출원하였다. 그런데 甲은 최근 특허청 심사관으로부터 거절이유가 기재된 의견제출통지서를 수령하였다.

(1) 이 사안에서 거절이유를 초래한 선등록서비스표권의 소유형태에 대하여 설명하시오. (13점)

(2) 특허청 심사관의 거절이유에 대하여 서술하고, 그 타당성에 대하여 논하시오. (12점)

(3) 변리사 丙이 甲으로부터 甲의 출원상표에 대한 의견제출을 의뢰받은 경우 변리사 丙의 입장에서 출원상표의 거절이유를 극복하기 위하여 취할 수 있는 조치에 대하여 논하시오. (5점)

〈출제〉 49회 상표법 기출

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제점

민법상 공유규정 적용 판례 기재, 다만, 무체성을 고려한 민법상 준공유적 성질.
+法2③.

2. 선등록서비스표권의 소유형태

(1) 상표권의 공유 판단(사안포섭 적용)

(2) 선등록서비스표권의 공유에 따른 취급

1) 상표의 사용

2) 지분의 포기

(3) 상표의 특성에 의한 제한

①지분양도, 질권설정제한(法54⑤), ②사용권설정의 제한(法54⑥), ③ 갱신등록신청 등에 따른 제한(法43③, 法46의2④, 法48①(2)), ④심판청구에 따른 제한(法77②,③), ⑤심결취소소송의 원고적격, ⑥침해금지청구, ⑦손해배상청구의 제한.

(4) 공유에 대한 제한 규정 위반시 취급

- 1) 취소사유(法73①(4), 法73⑤)
- 2) 전환등록신청, 추가등록출원에 대한 거절이유
- 3) 부적법 각하

3. 기타 취급

- (1) 공유물 분할청구
- (2) 상표의 사용에 따른 문제점

4. 관련 문제

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제점

2. 法7①(7) 취지

3. 타인의 해당여부 판단

- (1) 판례의 태도
- (2) 검토 및 사안의 경우

4. 휘발유의 경우

- (1) 상표와 서비스표의 구분
- (2) 소극적 효력 범위
- (3) 판례에 따른 동종성 판단
- (4) 검토 및 사안의 경우

5. 자동차 백미러의 경우

동종성 없음.

6. 출원일체의 원칙

7. 소결

거절이유 통지 타당.

III. 설문(3)에 대하여

1. 문제점

2. 法7①(7)의 타인 요건에 대한 극복방안

(1) 法7③단서

(2) 사안의 포섭 (출원인 명의변경신청 또는 서비스표권 일부지분 양수)

3. 출원일체의 원칙 극복방안

삭제보정, 출원의 분할

[B-2] 상표권의 이전

상표권이 상표권자로부터 타인에게 이전되는 여러가지 경우가 있다. 이와 같이 상표권이 이전되는 특징적 절차, 효과 및 제한에 관하여 설명하시오. (20점)

〔출제〕 49회 상표법 기출

I. 문제의 소재

II. 상표권 이전의 태양 및 특징적 절차

1. 상표권 이전의 태양

일반승계, 특정승계/ 전부승계, 일부승계

2. 상표권 이전의 절차

특정승계의 경우 권리이전등록신청서, 일반승계 별도절차 不要.

III. 상표권 이전의 효과

1. 상표권 이전의 효력발생

특정승계의 경우 등록이 효력발생요건(法56①(1)), 일반승계는 당연승계 취지 신고(法56②).
이전등록 지연시 제재(法64).

2. 상표권 이전의 효과

(1) 판례의 태도 및 권리 승계

상표권이라는 물에 대한 취급 → 法73①(2),(3)/ 무효사유 승계

(2) 사용권 및 절차에 대한 취급

IV. 상표권 이전의 제한

1. 상표권의 성질에 따른 제한

유사지정상품(法54①단서), 공유에 따른 제한(法54⑤)

2. 특유표장에 대한 제한

- (1) 업무표장/ 증명표장/ 단체표장
- (2) 마드리드 의정서

3. 이전제한 위반의 효과

V. 소결 및 관련문제

- 1. 상표권 분할 후의 이전
- 2. 상표권의 이전과 사해행위 취소에 따른 취급(判例)
- 3. 특허법과의 비교(특히, 출원단계의 특허를 받을 수 있는 권리가 상표에는 없음)